

刑事手続の各段階における前科の扱いに関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

ア. 常習累犯窃盗罪のように前科が構成要件の一部を構成している場合や、常習賭博罪のように構成要件としての常習性を認定する場合でなければ、被告人の同種前科をもって、犯罪事実を立証することは許されない。

イ. 累犯加重の理由となる前科については、適法な証拠調べをした証拠によらなければ認定することはできない。

ウ. 勾留中の被告人について保釈の請求があった場合、その許否を決するに当たっては、勾留状に記載された事実以外の犯罪事実を考慮してはならず、被告人の前科を考慮することは許されない。

エ. 起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめるおそれのある内容を引用してはならないから、常習累犯窃盗罪のように前科が構成要件の一部を構成している場合でなければ、起訴状に被告人の前科を記載することは許されない。

オ. 検察官は、執行猶予中の被疑者が再度その前科と同種の犯罪に及んだ場合であっても、犯罪の軽重及び情状等を考慮して、公訴を提起しないことができる。

1. ア イ 2. ア ウ 3. イ オ 4. ウ エ 5. エ オ

ア 誤っている

最大決昭 41.11.22。被告人の犯罪事実を立証するために同種前科の存在やその内容を用いることは、前科から被告人の悪性格を推認し、その悪性格から公訴事実を被告人が行ったことを推認するという二重の推認過程を経ることから、典型的に事実認定を誤らせるおそれがあるとして、原則として法律的関連性を欠くため、許されない（悪性格の立証）。本記述では、常習累犯窃盗のように前科が構成要件の一部を構成している場合や、常習賭博罪のように構成要件としての常習性を認定する場合でなくとも、被告人の同種前科をもって、犯罪事実を立証することが許されるかが問題となる。

この点、判例は、「犯罪の客観的要素が他の証拠によつて認められる本件事案の下において、被告人の詐欺の故意の如き犯罪の主観的要素を、被告人の同種前科の内容によって認定した原判決に所論の違法は認められない」として、犯罪事実の主観的要素について被告人の同種前科をもって立証することを許容している。学説においても、例外的に、故意、目的、動機、知情等、犯罪の主観的要素を証明する場合には、前科を用いた犯罪事実の認定が許されるとされている。なぜなら、このような場合には、他の犯罪事実（前科）から公訴事実に関する主観的な要素を直接に推認するのであるから、その証明力は悪性格を介在させた推認の場合のような不確実なものとは異なり、経験則、論理則に基づく合理的な推認として、証拠の証明力が高く、事実認定を誤らせるおそれが低い場合に当たるので、これを禁ずる理由はないといえるからである。

よって、常習累犯窃盗のように前科が構成要件の一部を構成している場合でなくとも、被告人の同種前科をもって、犯罪事実を立証することが許される場合もある。したがって、本記述は、前科が構成要件の一部を構成している場合でなくとも、被告人の同種前科をもって、犯罪事実を立証することが許される場合もあるとすべきところ、これを許されないとしている点で、誤っている。

イ 正しい

最大決昭 33.2.26（百選A31 事件）。本記述では、累犯加重の理由となる前科については、適法な証拠調べをした証拠によって認定しなければならないかが問題となる。この点、判例は、「累犯加重の理由となる前科……を認定するには、証拠によらなければならないことは勿論、これが証拠書類は刑訴 305 条による取調をなすことを要する」としている。その理由として、判例は、「累犯加重の理由となる前科は、刑訴 355 条にいわゆる『罪となるべき事実』ではないが、かかる前科の事実、刑の法定加重の理由となる事実であつて、実質において犯罪構成事実に準ずるものである」ということを挙げている。したがって、本記述は正しい。

ウ 誤っている

最大決昭 44.7.14（百選A28 事件）。本記述では、勾留中の被告人について保釈の請求があった場合、その許可を決定するに当たって、勾留状に記載された事実以外の犯罪事実として、被告人の前科を考慮することが許されるかが問題となる。この点、判例は、裁量保釈（90 条）の許可を審査するに当たり、「被告人が甲、乙、丙の3個の公訴事実について起訴され、そのうち甲事実のみについて勾留状が発せられている場合において」、裁判所が「保釈が適当であるかどうかを審査するにあたっては、甲事実の事案の内容や性質、あるいは被告人の経歴、行状、性格等の事情をも考察することが必要であり、そのための一資料として、勾留状の発せられていない乙、丙各事実をも考慮することを禁ずべき理由はない」としている。よって、保釈の請求があった場合、その許可を決定するに当たって、勾留状に記載された事実以外の犯罪事実として、被告人の前科を考慮することは許される。したがって、本記述は、保釈の請求があった場合、その許可を決定するに当たって、被告人の前科を考慮することは許されるとすべきところ、これを許されないとしている点で、誤っている。なお、令和5年改正に

より 344 条 2 項が創設され、拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者についての裁量保釈は、保釈された場合に被告人が逃亡するおそれの程度が高くないと認めるに足る相当な理由が無い限り、被告人が受ける不利益の程度が著しく高い場合でなければならないこととなった。

エ 誤っている

最大判昭 27.3.5。本記述では、起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめるおそれのある内容を引用してはならないとされるところ(256 条 6 項、起訴状一本主義)、常習累犯窃盗罪のように前科が構成要件の一部を構成している場合でなければ、起訴状に被告人の前科を記載することが許されないかが問題となる。この点、詐欺罪(刑法 246 条)の被告事件において、判例は、「被告人は詐欺罪により既に 2 度処罰を受けたものであるが」と記載することについて、このような記載は、「公訴犯罪事実につき、裁判官に予断を生ぜしめるおそれのある事項にあたると解しなければならない」としながらも、続けて、「被告人の前科であっても、それが、公訴犯罪事実の構成要件となっている場合(例えば常習累犯窃盗)又は公訴犯罪事実の内容となっている場合(例えば前科の事実を手段方法として恐喝)等は、公訴犯罪事実を示すのに必要であって、これを一般の前科と同様に解することはできないからこれを記載することはもとより適法である」として、**例外的に起訴状に前科を記載することが許される場合を認めている**。よって、判例によれば、起訴状に被告人の前科を記載することが許されるのは、常習累犯窃盗罪のように前科が構成要件の一部を構成している場合に限られるわけではない。したがって、本記述は、前科が構成要件の一部を構成している場合でなくとも、起訴状に被告人の前科を記載することが許される場合があるとすべきところ、前科が構成要件の一部を構成している場合でなければ起訴状に被告人の前科を記載することは許されないとしている点で、誤っている。

オ 正しい

248 条。本記述では、検察官が、執行猶予中の被疑者が再度その前科と同種の犯罪に及んだ場合であっても、犯罪の軽重及び情状等を考慮して、公訴を提起しないことができるかが問題となる。この点、同条は、犯罪の嫌疑があり訴訟条件が備わっていても、犯人の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の状況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができるとして、検察官に起訴・不起訴についての裁量(起訴裁量)を認める、起訴便宜主義を採用している。起訴便宜主義が採用された趣旨は、起訴便宜主義は、起訴法定主義(起訴に充分なだけの客観的嫌疑があるときは、訴訟要件が具備されている限り必ず起訴すべきものとする制度)と対をなす制度であり、公訴権の適正な運用により、具体的正義の実現に奉仕し、偶発的で軽微な犯罪を訴追しないことにより犯罪者としての烙印を押すことを避け、早期に行方者に社会復帰・更生の機会を与えることができ、また、社会的に重大な犯罪訴追に注力することで刑事司法上の資源を有効に利用できるということにある。それゆえ、執行猶予中の被疑者が再度その前科と同種の犯罪に及んだからといって、直ちに起訴裁量を逸脱するというわけではない。よって、検察官は、執行猶予中の被疑者が再度その前科と同種の犯罪に及んだ場合であっても、犯罪の軽重及び情状等を考慮して、公訴を提起しないことができる。したがって、本記述は正しい。

以上により、正しい記述はイとオであり、したがって、正解は肢 3 となる。

